

1510316-08.2020.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... declarou que já foi preso por furto e tráfico. Em setembro de 2019 foi solto, mas não conseguia emprego. No dia dos fatos, discutiu com sua amásia e, por isso, saiu de casa e se dirigiu ao Shopping Piracicaba para verificar sua situação trabalhista na antiga loja "Califa", na qual já havia trabalhado. Caminhando no shopping, avistou um celular sob o balcão e aproveitou-se da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1510316-08.2020.8.26.0451

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2093136/2020 - 4º Distrito Policial de Piracicaba, 560/2020 - DEL.SEC.PIRACICABA, 78/2020 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Piracicaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Herik Fernando Tullio

Contr. nº 2020/000579

Aos 30 de novembro de 2022, às 14:40 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e 208/22 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Antonio Carlos Perez Antunes da Silva foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu HERIK FERNANDO TULLIO. Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: Marina Rodriguez Gonzales, PC James Batista Tavares e PC Fábio Luis Gonçalves Hilsdorf. Ausente a testemunha comum: Ana Carolina Gutierrez Mendes dos Santos.

Foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o acusado e todos os presentes foram retirados da sala, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o ré e sua defesa.

Antes da gravação da audiência, entretanto, o acusado, que estava presente no Fórum de Piracicaba, deixou o local, sem justificativa.

A seguir, pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que, verificado que o acusado encontrava-se egresso, que compareceu para a audiência e saiu, sem justificativa, DECRETAVA a REVELIA do réu, com base no artigo 367 do C.P.P.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (Marina e PC James) foram gravados em áudio e vídeo. Dada a palavra ao Dr. Promotor e a Defesa foi dito que desistiam das oitivas das testemunhas Ana Carolina e PC James, o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a). A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências. Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido. Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). HERIK FERNANDO TULLIO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, c.c. 14, inciso II, e 155, caput, todos do Código Penal, em continuidade delitiva (por duas vezes), porquanto no dia 08 de fevereiro de 2020, no período da tarde, no shopping Piracicaba, situado na Avenida Limeira, nº 722, Bairro Vila Rezende, nesta cidade e comarca de Piracicaba, tentou subtrair, para si, a quantia de R\$700,00, pertencente ao estabelecimento Magnólia, somente não consumando à infração por circunstâncias alheias a sua vontade. Consta do incluso inquérito policial que, no dia mesmo dia e local, nesta cidade e comarca de Piracicaba, subtraiu, para si, um aparelho celular, marca Samsung, modelo S7, pertencente a Marina Rodriguez Gonzales. (fls. 126/128) O processo teve trâmite regular, sendo o réu citado, ouvida a vítima e testemunhas e, após, interrogado. É este o relato do necessário. A ação penal é procedente.

A materialidade restou confirmada nos autos pela prova oral e ações flagradas por câmeras a fls. 10/13. Da mesma forma, a autoria delitiva. DE fato, a vítima Marina, ainda na fase informativa em juízo informou que estava atendendo um cliente e deixou seu celular ao lado do caixa. O réu pegou o celular e saiu andando. Uma cliente lhe avisou e saiu correndo atrás mas perdeu ele de vista. Pelas filmagens, conseguiu ver ele furtando. A Ana do quiosque Magnólia lhe contou que o réu pegou dinheiro e foi surpreendido por ela, devolvendo a quantia. Já o policial James contou que fez diligências no bosque dos Lenheiros. Ele confessou que subtraiu o celular no quiosque Milkândia e que tentou pegar dinheiro de um caixa. Ele informou que vendeu o celular para uma pessoa no ponto de ônibus em frente ao shopping. Assim, de rigor a condenação do réu. Com efeito, o acusado foi flagrado pelas câmeras da loja Milkândia no momento em que subtraiu o celular de uma das funcionárias, sendo, aliás, reconhecido por ela posteriormente. Outrossim, a vítima da loja Magnolia na fase informativa relatou o ocorrido em sua loja, sendo sua informação corroborada pela outra vítima Marina e pelo policial James. Este último, aliás, confirmou que o réu confessou as práticas delitivas, o que foi documentado a fls. 18. Diante do acima exposto, requer o Ministério Público a condenação do réu nos termos acima propostos. Na aplicação da pena há que se observar que o réu é multirreincidente, inclusive específico (certidões a fls. 152/155)

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). HERIK FERNANDO TULLIO foi denunciado, por duas vezes, pela prática do crime previsto no art. 155, do Código Penal, uma delas na modalidade tentada, conforme os fatos narrados na inicial acusatória. Encerrada a instrução processual, o Ministério Público se manifestou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defensoria Pública passa então a se manifestar. A ação penal deve ser julgada improcedente, por falta de provas. O réu teve a revelia decretada, porém isso não pode ser considerado em seu prejuízo, já que poderia simplesmente ficar em silêncio, em exercício de direito constitucional expressamente previsto. A incriminá-lo foram ouvidas as vítimas e os investigadores de polícia, porém esses depoimentos não são suficientes para condená-lo, haja vista que a pessoa ofendida não presta o compromisso de dizer a verdade, e os agentes policiais evidentemente buscaram legitimar seus atos, de modo que não podem ser consideradas testemunhas totalmente isentas. Assim, pela fragilidade do conjunto probatório, o requerimento da defesa é para que Vossa Excelência decrete a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Caso, no entanto, o entendimento seja diverso, requer-se a fixação da pena no mínimo legal. O réu é reincidente, mas há atenuante da confissão, já que na fase

policial admitiu o crime. Ambas são circunstâncias igualmente preponderantes, de forma que devem ser integralmente compensadas. Ao réu foram imputadas duas infrações. Pelo que se verifica estão presentes os requisitos do artigo 71, do Código Penal, que trata do crime continuado. Foram, em tese, cometidas duas subtrações no mesmo local – shopping center – em curtíssimo intervalo de tempo. O modus operandi também foi o mesmo. Assim, reconhecido o crime continuado, aplica-se a pena do delito mais grave (furto consumado) com o aumento de um sexto. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, pugna para que seja fixado regime diverso do fechado, sobretudo porque a Súmula 269, do STJ, assim autoriza. Ausentes os requisitos da prisão preventiva, requer-se seja permitido ao acusado que apresente eventual apelação em liberdade.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos.

HERIK FERNANDO TULLIO, nos autos qualificado, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso nos artigos 155, caput, c.c. 14, inciso II, e 155, caput, todos do Código Penal em continuidade delitiva (por duas vezes), porque, segundo a denúncia, no dia 08 de fevereiro de 2020, no período da tarde, no shopping Piracicaba, situado na Avenida Limeira nº 722, Bairro Vila Rezende, nesta cidade e comarca de Piracicaba, tentou subtrair, para si, a quantia de R\$700,00, pertencente ao estabelecimento Magnólia, somente não consumando à infração por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta que, no mesmo dia e local, subtraiu, para si, um aparelho celular, marca Samsung, modelo S7, pertencente à Marina Rodriguez Gonzales.

Narra a denúncia que no dia dos fatos, o acusado se dirigiu ao Shopping Piracicaba com a intenção de praticar furtos. Foi até o quiosque “Magnólia” lá localizado e, enquanto a funcionária atendia outros clientes, pegou a quantia de R\$ 700,00 do caixa. Todavia, foi surpreendido pela vítima, razão pela qual devolveu o dinheiro. Em seguida, dirigiu-se até o quiosque “Milkândia”, também situado no interior do Shopping, e, aproveitando-se da distração da funcionária, apossou-se do seu aparelho celular, o qual se encontrava guardado na parte interna do balcão. Ato contínuo evadiu-se na posse do bem.

A denúncia foi recebida em 07/02/2022 (fls. 141). O réu foi citado pessoalmente (fl. 160). Defesa preliminar apresentada às fls. 164/165. Após, foi mantido o recebimento da denúncia (fl. 166).

Durante a instrução foram ouvidas uma vítima e uma testemunha arrolada pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça requereu o acolhimento da denúncia, com condenação do réu, alegando estarem comprovadas autoria e materialidade dos crimes.

A Defesa pleiteou a absolvição por falta de provas.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade e autoria delitivas foram comprovadas pelos seguintes elementos:

- 1) boletins de ocorrência de fls. 03/04 (loja Milklandia) e 05/06 (loja Magnolia);
- 2) relatórios de investigações de fls. 07/11 e de fls. 12/14, ambos com imagens da ação criminosa;
- 3) auto de reconhecimento fotográfico de fls. 16, documentando o reconhecimento do réu feito vítima Ana Carolina, do quiosque Magnolia;

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Ouvido na fase informativa (fls. 18), o acusado declarou que já foi preso por furto e tráfico. Em setembro de 2019 foi solto, mas não conseguia emprego. No dia dos fatos, discutiu com sua amásia e, por isso, saiu de casa e se dirigiu ao Shopping Piracicaba para verificar sua situação trabalhista na antiga loja “Califa”, na qual já havia trabalhado. Caminhando no shopping, avistou um celular sob o balcão e aproveitou-se da distração da vendedora para subtrair o aparelho. Afirmou tê-lo vendido para uma pessoa desconhecida que estava em um ponto de ônibus, pelo valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Disse que já havia sido internado em

clínica de dependência química na cidade de Itu.

Em juízo o réu não exerceu sua autodefesa, posto que revel.

A confissão foi corroborada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvida na fase informativa (fl. 15), a representante da empresa vítima Magnólia, Ana Carolina Gutierrez Mendes dos Santos, declarou que o réu tentou subtrair dinheiro do caixa da loja na qual trabalhava e, depois, vendo as imagens do furto praticado no outro estabelecimento, reconheceu-o como autor do crime. Por sua vez, a vítima Marina Rodrigues Gonzales, ouvida na fase informativa (fl. 17) e sob o crivo do contraditório (gravação), declarou que trabalhava no quiosque "Milklandia". No dia dos fatos, como de costume, deixou seu celular na prateleira, na parte interna do balcão e, posteriormente, percebeu que o aparelho havia sido subtraído. Ao rever as imagens captadas pelas câmeras de monitoramento de segurança instaladas no local constatou que um indivíduo de cor branca, magro, boné preto e camiseta branca, havia subtraído o aparelho no momento em que ela se distraiu para atender um cliente. Informou que teve conhecimento através de um funcionário do shopping de que um indivíduo com as mesmas características e vestimentas teria tentado subtrair dinheiro do caixa do quiosque "Magnolia". Foi até o referido quiosque e manteve contato com a funcionária Ana (vítima), a qual confirmou a tentativa de furto naquele estabelecimento e disse que conseguiu impedir o agente de consumá-lo arrancando o dinheiro da mão dele.

Não há por que se duvidar da palavra das vítimas, pessoas essas que não tinham motivos para incriminar injustamente o réu, pessoa que sequer conheciam anteriormente.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, em crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas tem especial importância na revelação dos fatos e do sujeito ativo:

"APELAÇÃO - FURTOS SIMPLES, QUALIFICADO E RECEPÇÃO - Materialidade e autoria delitivas satisfatoriamente demonstradas - Palavras das vítimas firmes e coesas, corroboradas pelo restante do conjunto probatório - Validade - Ausência de interesse em prejudicar os acusados - Negativas que restaram isoladas - Aplicação do princípio da insignificância - Impossibilidade - Réu Marcelo que é reincidente - Acusado Rafael que, embora tecnicamente primário, é investigado por delito da mesma espécie, revelando não ser um fato isolado - Desvalor da conduta que também deve ser sopesado, não apenas o valor do bem subtraído - Circunstâncias que evidenciam o pleno conhecimento de Marcelo sobre a origem ilícita do bem receptado - Penas e regimes bem fixados - Recursos desprovidos". (TJSP - Apelação Criminal 1500129-47.2018.8.26.0600. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Edison Brandão - j. 06/05/2020) - g.n.

"Justiça gratuita - Isenção do pagamento de custas e despesas processuais - Inadmissibilidade - Matéria afeta ao Juízo da VEC A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetadas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira. Furto - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais - Validade - Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuarão a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Pena - Condenado reincidente em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça - Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena - Entendimento Em se tratando de condenação por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, cujo agente seja reincidente, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2º, "c",

do CP". (TJSP - Apelação Criminal 0001883-83.2016.8.26.0369. Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Grassi Neto - j. 24/09/2020) - g.n. Ademais, os relatos das ofendidas encontram amparo nos depoimentos dos policiais acionados para atender a ocorrência.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 21) e sob o crivo do contraditório (gravação), o policial civil James Batista Tavares, declarou que, através do policial Fábio, teve conhecimento de um furto praticado no quiosque "Milklandia", situado no Shopping Piracicaba. Soube, ainda, que referido policial esteve no local onde teve acesso às imagens do circuito interno daquele estabelecimento. Ademais, ele obteve informações de terceiros apontando o agente como sendo um ex-funcionário de uma loja daquele Shopping, identificado como sendo o réu Herik. Durante a apuração desse crime, seu colega teve conhecimento de que um agente com as mesmas características também teria tentado subtrair dinheiro do caixa de um outro quiosque lá existente, denominado "Magnolia". Munidos dessas informações, realizaram um levantamento e verificaram que a vítima Marina havia registrado o B.O. de nº 560/2020, referente ao furto do aparelho, no quiosque, Milklandia, bem como que Ana Carolina havia registrado outro B.O. de nº 078/2020 (DIG), de tentativa de furto de valores no quiosque Magnolia. Diante disso, de posse do nome do suspeito, efetuaram levantamento dos registros policiais e fotos, e conseguiram chegar à pessoa do acusado. Diligenciaram à procura dele, conseguiram localizá-lo e intimá-lo para comparecer na DIG. Na delegacia, ele foi submetido a reconhecimento pessoal pela vítima Ana, o qual resultou positivo. Esclareceu que a vítima Marina não viu o acusado subtraindo o celular, pois estava de costas no momento dos fatos. Contudo, a conduta do réu foi registrada pelo circuito interno do quiosque. Por fim, afirmou que, após serem exibidas as imagens da cena criminosa ao réu, este confessou a subtração do aparelho celular do quiosque, bem como a tentativa de subtração do dinheiro do caixa do outro quiosque, alegando que não conseguiu consumir esse outro delito porque foi surpreendido pela funcionária. Admitiu, por fim, que vendeu o aparelho celular subtraído por R\$ 150,00.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 63/64) pelo policial civil Fábio Luis Gonçalves Hilsdorf.

Anoto que os relatos dos policiais civis merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar suas palavras na valoração das provas.

Neste sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

Diante deste contexto, não há dúvidas das práticas delitivas pelo acusado.

De fato, o acusado confessou informalmente os dois delitos e, perante a Autoridade Policial confessou o furto consumado (fls. 18).

A vítima Ana fez o reconhecimento fotográfico do acusado na delegacia (fls. 16).

O furto consumado no quiosque "Milklandia" foi captado e registrado por câmeras de segurança.

Assim, restaram comprovadas as duas infrações penais, sendo a primeira na forma tentada, eis que o réu foi impedido de consumir a subtração em razão da intervenção da funcionária do quiosque, que o viu pegando o dinheiro do caixa e o impediu de leva-lo.

Fixada, dessa forma, a responsabilidade penal do réu, passo à individualização das

penas.

As circunstâncias mencionadas no artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

Assim, fixo as penas bases em um ano de reclusão de dez dias-multa para cada crime. O réu tem a seu favor a atenuante da confissão da autoria dos crimes.

Por outro lado, presente a agravante da reincidência devido a condenações por tráfico de drogas e furtos (fls. 152/153: proc. 0015274-92.2012.8.26.0451 e proc. 0017155-07.2012.8.26.0451, ambas penas cumpridas aos 23/07/2017; fls. 153: proc. 0024518-16.2010.8.26.0451, extinta a punibilidade aos 22/10/2015; fls. 153/154: 1500344-26.2018.8.26.0599, com transito em julgado para as partes aos 17/01/2019). Tratando-se de multirreincidência, a atenuante da confissão compensa em parte o aumento da pena pela reincidência, de modo que esse aumento se dará na fração mínima de 1/6, perfazendo um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa para cada delito.

Assim determinou o C. Superior Tribunal de Justiça nos v. acórdãos de revisão de tese nos Recursos Especiais n. 1.947.845/SP e n. 1.931.145/SP, os quais transitaram em julgado, processos-paradigma do Tema n. 585 – Compensação – Possibilidade – Confissão – Reincidência, que passou a vigorar com a seguinte tese:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

De rigor o reconhecimento da tentativa em relação ao primeiro delito, eis que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que foi surpreendido pela funcionária no momento da subtração do dinheiro do caixa.

Em razão da tentativa e considerando que o “iter criminis” não foi interrompido logo no início, pois ele já tinha se apossado do dinheiro quando foi surpreendido, diminuo as penas em 1/2, perfazendo sete meses de detenção e cinco dias-multa.

Não há causas de aumento de penas.

Tendo em vista que os crimes foram praticados em continuidade delitiva, ou seja, em semelhantes circunstâncias de tempo, local e modo de execução, com fundamento no artigo 71 do Código Penal, aplico a pena do mais grave, mas aumentada em 1/6, o que perfaz um ano, quatro meses e dez dias de reclusão e doze dias-multa.

Aplico esse percentual de aumento em razão do número de infrações, critério que vem sendo adotado para o aumento na continuidade delitiva.

Nesse sentido o entendimento da jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. AUMENTO DA PENA BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. PRÁTICA DO CRIME POR PELOS MENOS 10 VEZES. FRAÇÃO EMPREGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 2. O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal. 3. Cabível a exasperação da pena-base quando exposta fundamentação idônea diante da maior reprovabilidade da conduta da ré, que manteve a vítima em erro por tempo considerável, bem como pelas consequências do crime, que extrapolaram aquelas próprias do tipo, já que a vítima não se recuperou do trauma e teve elevado prejuízo financeiro. 4. Inexiste constrangimento ilegal na exasperação da pena na fração de 2/3, pela continuidade delitiva, em razão da prática do crime por pelo menos 10 vezes, na medida em que o STJ possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais

infrações (AgRg no HC 651.735/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDF, Quinta Turma, DJe de 24/9/2021). 5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 649.199/SP. Quinta Turma. relator Ministro João Otávio de Noronha - j. 15/2/2022) - g.n.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária ou restritiva de direitos, bem assim a concessão do "sursis", visto que não preenchidos os requisitos legais (réu multirreincidente específico).

Em razão da multirreincidentência específica, nos termos do artigo 33, do Código Penal, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena corporal.

Por não haver condições de se apurar a atual condição econômica do réu, fixo cada dia-multa no valor mínimo legal.

Por fim, deixo de acolher o pedido para fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados pelo furto consumado, uma vez que não foi indicado o valor exato da "res", não havendo provas suficientes e seguras do prejuízo causado, tal como nota fiscal comprovando o preço do aparelho subtraído.

Isso seria imprescindível para que o réu exercesse a ampla defesa e o contraditório também em relação ao pedido de condenação ao pagamento de indenização, até para que pudesse fazer contraprova que indicasse valor diverso do pleiteado.

Entendo que, mesmo se tratando de processo penal, para que haja condenação do réu ao pagamento de indenização à vítima, o que terá efeitos civis e não penais, devem ser aplicadas as normas de processo civil, que exigem indicação precisa e pormenorizada do valor pleiteado a título de indenização, com comprovação exata do dano provocado, o que inexistente nos autos.

Neste sentido a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in Código de Processo Penal Comentado, Forense, pp. 917/918: "Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida a infringência ao princípio da ampla defesa" - gn.

No mesmo rumo vem decidindo o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Apelações 0002272-83.2008.8.26.0584 (4ª Câmara, Des. Rel. Euvaldo Chaib) e 3000503-89.2007.8.26.0077 (11ª Câmara, Des. Rel. Guilherme G. Strenger).

Nada impede, contudo, que a indenização seja discutida, de forma específica, no Juízo Cível, onde a parte lesada terá oportunidade de defender seus direitos, podendo quantificar o valor do prejuízo, comprovar o valor exato do aparelho subtraído e pleitear a devida reparação.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu HERIK FERNANDO TULLIO a cumprir um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, e a pagar doze dias-multa, no mínimo legal, por ter infringido os artigos 155, caput, c.c. 14, inciso II, e 155 caput, todos do Código Penal, em continuidade delitiva (por duas vezes).

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, deixo de decretá-la, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA da acusação ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data para o MP.

Intime-se o(a) ré(u) do teor da sentença, bem como se dela deseja recorrer. Com a juntada do mandado, devidamente cumprido, dê-se vista à Defensoria Pública para eventual interposição de recurso.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(^a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.